

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、乙を教唆して丙所有の骨董品を盗むことを決意させ、乙にこれを実行させた後、同人が丙から盗んだ骨董品を買い受けた。甲には、窃盗教唆罪及び盗品等有償譲受け罪が成立し、両罪は併合罪となる。
2. 甲は、脇見しながら自動車を運転したため、自車前方で信号待ちのため停車していた乙運転の自動車に気付くのが遅れ、同車に自車を追突させ、その衝撃で乙運転の自動車を前方に押し出し、同車の前方に停車中の丙運転の自動車に追突させ、これにより乙が死亡し、丙は傷害を負った。甲には、乙に対する過失運転致死罪及び丙に対する過失運転傷害罪が成立し、両罪は併合罪となる。
3. 甲は、乙を殺害する目的で、乙の住居に侵入し、同住居内で乙を殺害した。甲には、住居侵入罪及び殺人罪が成立し、両罪は併合罪となる。
4. 甲は、自宅で乙を殺害し、その死体を遠方の山林に埋めた。甲には、殺人罪及び死体遺棄罪が成立し、両罪は牽連犯となる。
5. 甲は、乙から同人名義のクレジットカードを窃取し、Aデパートにおいて、店員に対し、乙に成り済まして同クレジットカードを呈示して商品の購入方を申し込んだが、同店員に盗難カードであることを見破られたため、商品を手に入れることができなかった。甲には、窃盗罪及び詐欺未遂罪が成立し、両罪は牽連犯となる。

*平成25年11月27日法律第86号により、自動車運転過失致死傷罪は、旧刑法211条2項から自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条に移され、罪名も過失運転致死傷罪に改められた。そのため、記述2については改題をした。

№188	罪数論の具体例	正答率
H20-17	正解 1	92%

1 正しい

大判明 42.3.16。本記述と同様の事案において、判例は、窃盗教唆罪（61 条 1 項、235 条）と盗品等有償譲受け罪（256 条 2 項）とは併合罪（45 条）になるとしている。その理由として、判例は、両者の間に「通常手段又は結果の関係はない」ということを挙げている（大判明 42.3.16）。

2 誤っている

本記述では、乙に対する過失運転致死罪（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律）と丙に対する過失運転傷害罪（同法）との関係が問題となる。1 個の行為から 2 個以上の罪名に触れる結果が発生した場合、観念的競合（54 条 1 項前段）となる。判例は、観念的競合の判断基準につき、「法的評価をはなれ構成要件の観点から捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上一個のものとの評価をうける場合をいう」としている（最大判昭 49.5.29、百選 I 104 事件）。本記述では、乙に対する過失運転致死罪と丙に対する過失運転傷害罪は、甲の追突行為という社会的見解上一個のものとの評価を受ける行為から発生した結果であるから、観念的競合となる。

3 誤っている

判例は、住居侵入罪と殺人罪の場合について牽連犯の関係を肯定している（大判明 43.6.17）。その理由として、判例は、屋内にいる人を殺害するために家宅へ侵入する行為は殺人罪の構成要素をなすものではなく、殺人行為の手段であるということを挙げている。

4 誤っている

判例は、殺人罪と死体遺棄罪とは併合罪になるとしている（大判明 44.7.6）。その理由として、判例は、死体遺棄行為は常に必ず殺人行為を伴うものではなく、人を殺した後に死体を遺棄する行為は別罪を構成することを挙げている。

5 誤っている

窃取した郵便貯金通帳を利用して払戻名下に金員を詐取した事案において、判例は、併合罪になるとしている（最判昭 25.2.24）。その理由として、判例は、「窃取または騙取した郵便貯金通帳を利用して郵便局係員を欺罔し真実名義人において貯金の払戻を請求するものと誤信せしめて貯金の払戻名義の下に金員を騙取することはさらに新法益を侵害する行為であるからここに亦犯罪の成立を認むべき」ということを挙げている。本記述では、甲は窃取した乙名義のクレジットカードを呈示して商品の購入方を申し込んでおり、新たな法益を侵害しており、窃盗罪とは併合罪になる。